

1500995-29.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500995-29.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500995-29.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145852/2022 - DEL.POL.ITAPEVI, 25252998 -

DEL.POL.ITAPEVI, 2145852 - DEL.POL.ITAPEVI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR COELHO FERREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

JOÃO VICTOR COELHO FERREIRA e LUIZ FILLIPE DE SOUZA DUARTE, qualificados nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhes move a Justiça Pública, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque, no dia 29 de maio de 2022, por volta das 14h10min, na Avenida Leda Pantalena, n.º 2270, Jardim Portela, nesta cidade e Comarca de Itapevi, os réus, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo e transportavam drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados e apresentaram defesa prévia (f. 165-178 e 259-271).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial acusatória foi recebida por decisão datada de 03 de agosto de 2022, na qual também

restou indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo réu João Victor Coelho Ferreira e, ainda, foi deferido o pedido de restituição do veículo apreendido nos autos em favor de Localiza Rent a Car S.A. (f. 313-315). Os réus foram citados, dando-se seguimento à persecução penal em Juízo. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação e duas da defesa, tendo-se interrogado os réus ao final (f. 389). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (f. 387-388). Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa aos acusados a prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de f. 05-06, que atesta terem sido apreendidos os entorpecentes em posse dos acusados, bem como dois aparelhos de telefone celular, um veículo e a quantia de R\$ 1.822,00 em dinheiro.

As substâncias entorpecentes foram submetidas a exame pericial (f. 278-280), sendo que o resultado foi positivo para "maconha", droga de uso proscrito no Brasil.

Os réus, em seus interrogatórios, confessaram a prática dos fatos narrados na exordial acusatória.

As confissões, aliás, restaram corroboradas pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Deveras, os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram contestes nos pontos essenciais e confirmaram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Relatam que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando viram os réus sentados na calçada com atitude suspeita. Informam que um dos réus, Luiz Fillipe de Souza Duarte, quando avistou a viatura, levantou-se e demonstrou a intenção de se evadir do local, ao que o outro, João Victor Coelho Ferreira, o acalmou, para que ele ficasse parado. Abordaram-nos, então, e passaram a formular perguntas. O acusado João Victor Coelho Ferreira se identificou como policial militar e, por não saberem se a funcional era verdadeira ou não, revistaram-no. Em sua posse, nada havia de ilícito, apenas uma quantia em dinheiro. Perguntaram a ele onde estava a arma, e o réu disse que estava no porta-luvas do carro. O acusado Luiz Fillipe de Souza Duarte estava muito nervoso e falou que havia algo ilícito no veículo. Realizaram, então, a busca veicular e, logo, sentiram um forte cheiro de maconha. Abriram o porta-malas e, lá dentro, havia as porções de drogas.

E nada há nos autos que indique eventual intenção espúria dos policiais militares de incriminar injustamente os acusados. Assim, seus depoimentos merecem credibilidade e são valiosos para a condenação. Entendimento contrário acarretaria a ruína do sistema de segurança pública do Estado.

Frise-se, nesse passo, que as circunstâncias da abordagem, noticiadas nos depoimentos dos policiais, permitem presumir que as drogas apreendidas com os acusados se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

E não é caso de se aplicar o entendimento do C. STJ a respeito da justa causa para a busca veicular.

Explico.

A abordagem dos acusados pelos policiais militares foi precedida de justa causa, na medida em que um dos réus levantou-se do chão e demonstrou a intenção de correr assim que avistou a viatura de polícia – só não o fez porque foi dissuadido pelo corréu.

Os policiais militares acharam a conduta suspeita e, em face disso, abordaram-nos e começaram a dirigir-lhes algumas perguntas. Nesse momento, o réu Luiz Fillipe de Souza Duarte ficou ainda mais nervoso e, não demorou muito, informou ao policial que estava com ele que havia coisa ilícita no veículo.

A par de toda essa conduta suspeita – pra dizer o mínimo – os policiais sentiram um forte cheiro de maconha vindo de dentro do veículo, o que, junto com os demais elementos, embasou a busca veicular, onde foram encontradas as drogas.

Patente, pois, a existência de justa causa na abordagem dos policiais e na busca realizada no veículo que estava em posse dos acusados.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação.

No que tange à aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, atento aos recentes julgados dos tribunais superiores sobre o assunto, revejo posicionamento anterior e passo a não vislumbrar inconstitucionalidade na incidência deste privilégio.

Explica-se.

A Terceira Seção do C. STJ, embora não tenha se pronunciado diretamente sobre a inconstitucionalidade ou não da causa especial de diminuição de pena em tela, ao revisar o REsp n.º 1.329.088/RS, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC), no Tema n.º 600, firmou a seguinte tese: “O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo”.

Com a revisão da tese anterior, o tribunal superior cancelou seu enunciado de súmula n.º 512, que assim dispunha: “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas”.

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

45) A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem.

46) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.

Em todos esses enunciados, bem como no Tema Repetitivo n.º 600, o C. STJ admitiu indiretamente a viabilidade de incidência da circunstância privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que observados cumulativamente os requisitos do dispositivo.

Também o STF firmou tese admitindo a aplicação do privilégio ao delito de tráfico, no julgamento do Tema n.º 712 de Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese: “As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

Desse modo, nada há que se falar sobre eventual inconstitucionalidade da norma disposta no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso concreto, os acusados fazem jus à aplicação da forma privilegiada do tráfico.

Com efeito, os réus são primários, possuem bons antecedentes (f. 378-379 e 380-381) e não há outros indícios de que se dediquem às atividades criminosas ou integrem organização criminosa.

Cabível, portanto, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

Nessa conjuntura, verifica-se que há subsunção das condutas dos acusados ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com vontade e consciência, traziam consigo e transportavam as porções de drogas indicadas na denúncia, sem autorização legal ou regulamentar.

O fato é ilícito, pois reprovado pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

Os denunciados eram maiores de 18 anos de idade (imputáveis), tinham potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhes exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

A par disso, tem-se que os denunciados não possuem maus antecedentes, nem há provas de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa, incidindo na espécie a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: “O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais” (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

A par disso, para a hipótese específica destes autos, incide o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que assim dispõe, in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Neste cenário normativo, verifica-se que dois vetores do art. 42 da Lei de Drogas já estão inseridos expressamente nos parâmetros do art. 59 do CP – “personalidade e conduta social do agente”. Outrossim, tem-se que “a natureza e a quantidade da substância ou produto” podem ser analisadas no contexto das “circunstâncias” do delito, outro vetor do art. 59 do CP.

Assim, e pela necessidade da “preponderância” prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, alvitra-se valorar a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias do delito, com um peso mais significativo.

Como ressaltado anteriormente, costuma-se considerar o intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito. Todavia, para preponderância aqui perseguida, prudente que a divisão seja feita por 11, uma vez que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas podem ser enquadradas em três vetores, tal como delineado acima – personalidade, conduta social e circunstâncias.

Fazendo isso, porém, deve-se dar aos vetores preponderantes o peso de 2/11, e aos demais, o de 1/11.

Assim, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/06, à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao

comportamento da vítima (irrelevante em se tratando de crime vago como o tráfico de drogas), deve-se atribuir o peso de 1/11, constituindo 5/11 da pena-base; à conduta social e à personalidade do agente, assim como às circunstâncias, deve-se aplicar o peso de 2/11, configurando 6/11 da pena-base.

Desse modo, estará garantida a aplicação preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, bem como assegurada, de forma mais escorreita e técnica, a individualização da pena.

Todavia, é necessário ressaltar que a fração indicada não deve ser aplicada de forma precisa, matematicamente. Trata-se, na verdade, de mero parâmetro para a fixação da reprimenda penal, de modo que as circunstâncias do caso concreto podem ensejar a exasperação maior ou menor da pena – ou maior ou menor compensação em caso de vetores favoráveis.

Feitas essas observações, à dosimetria da pena.

Pois bem, os acusados são primários e não ostentam maus antecedentes (f. 378-379 e 380-381).

Por outro lado, as circunstâncias do delito são desfavoráveis. Com efeito, os denunciados estavam na posse de expressiva quantidade de entorpecentes – 7,8kg de maconha (f. 278-280), e de uma considerável quantia em dinheiro, R\$ 1.822,00 juntos, o que indica já terem auferido lucro com o tráfico no momento da abordagem. As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis aos réus, ou são normais ao tipo penal.

Nesse contexto, havendo uma circunstância judicial preponderante negativa (circunstâncias do crime), fixo a pena base desse delito, para ambos os réus, em 06 anos e 08 meses de reclusão – e 666 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea para os dois acusados, na forma do art. 65, III, “d” do CP, tendo em vista que ambos confessaram em juízo a prática do delito.

Assim, ante a atenuante da confissão espontânea, reduzo as reprimendas em 1/6, fixando-as, provisoriamente, em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão – e 555 dias-multa.

Por fim, na última fase, incide a privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois os réus são primários, possuem bons antecedentes e não ficou demonstrada sua dedicação a atividades criminosas, tampouco sua integração em organização criminosa.

No ponto, como a quantidade das drogas encontradas em seu poder foi sopesada na primeira fase da dosimetria, a fim de evitar bis in idem e à míngua de outros critérios específicos, tem-se que a pena deve ser reduzida em 2/3. Dessa forma, fixo as reprimendas de ambos os réus, agora definitivamente, em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão – e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira dos denunciados, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento. Considerando o quantum da reprimenda fixada e o fato de o delito de tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado, apesar de grave, não ser crime equiparado a hediondo (Tema Repetitivo n.º 600 do STJ), fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Presentes os requisitos legais, e sendo a medida adequada e socialmente recomendável, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos para cada réu, a serem aplicadas pelo juízo da execução, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social no valor de três salários mínimos federais, tendo em vista a quantidade de drogas apreendida, necessitando de resposta mais enérgica da Justiça Pública.

Tendo em vista o desfecho da demanda, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se que não mais subsistem os pressupostos da prisão preventiva, de modo que os réus poderão recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos.

Em atenção à redação do art. 44, caput, da Lei n.º 11.343/06, ressalto que o STF,

no Tema de Repercussão Geral n.º 626, permitiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, fixando a seguinte tese: "É inconstitucional a vedação à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, prevista nos artigos 33, § 4º, e 44, caput, da Lei 11.343/2006".

A ação é apenas parcialmente procedente em razão da concessão do privilégio aos acusados.

Em razão do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para os seguintes efeitos:

(a) condenar o réu JOÃO VICTOR COELHO FERREIRA, já qualificado, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão - e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela infração ao art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A pena privativa de liberdade aplicada fica substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social no valor de 3 salários mínimos federais vigentes nesta data; e

(b) condenar o réu LUIZ FILLIPE DE SOUZA DUARTE, já qualificado, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão - e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela infração ao art. 33, caput e § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A pena privativa de liberdade aplicada fica substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social no valor de 3 salários mínimos federais vigentes nesta data.

O valor do dia-multa fica estabelecido, para ambos os réus, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente no país na data dos fatos, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados, caso os acusados estejam presos por este processo.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois se trata de crime vago.

Determino a perda dos bens apreendidos a favor da União, nos termos dos arts. 91, II, do CP e 63, I, da Lei n.º 11.343/2006, com exceção do veículo cuja restituição já foi deferida às f. 313-315.

Deixo de decretar a perda do cargo público do réu João Victor Coelho Ferreira em virtude do quantum de pena aplicado (art. 92, I, "b", do CP).

Custas pelos réus (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, "a"), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estarem litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhes fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

(a) lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados ou instituto equivalente;

(b) expeçam-se as guias de execução definitivas;

(c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação dos réus, com suas devidas identificações, acompanhadas do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelo art. 71, § 2º, do Código Eleitoral combinado com o art. 15, inciso III, da Constituição Federal;

(d) oficie-se ao Senad, nos termos do art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; e

(e) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Itapevi, 14 de dezembro de 2022.